REF. Nº 3562/09
MRA

SOBRE LEGALIDAD DE DECLARAR FUERA DE BASES A OFERENTES DE LICITACIÓN QUE INDICA.

TALCA, 20.OCT 09 *007020

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el Director Regional de Vialidad, quien en relación con la apertura técnica y económica del contrato denominado "Conservación Global de Caminos de las Redes Básica y Comunal de Teno, Romeral, Curicó y Rauco, Provincia de Curicó II Etapa, Región del Maule", requiere un pronunciamiento que determine acerca de la legalidad de la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación de las ofertas de dicha licitación, órgano que resolvió declarar a todos los oferentes fuera de bases, en razón de que ninguno de ellos dio cumplimiento a lo estipulado tanto en las bases generales como especiales en lo relativo a la forma de acompañar el documento "Análisis de Precio Unitario", el que en conformidad con lo informado por dicha comisión como asimismo por la Fiscal Regional del MOP, debió incluirse tanto en el sobre "Propuesta Técnica", como en el sobre caratulado "Propuesta Económica".

Al efecto, se explica en el informe emitido por la señalada fiscalía que en el punto 7.1 de las bases administrativas generales de licitación, al señalar los documentos que en un original y dos copias deben incluirse en el sobre "propuesta técnica", expresa que serán los que se señalan a continuación (.....), más los que se soliciten específicamente en las Bases Administrativas Especiales. Agrega que la letra g) de tal disposición contempla incluir dentro del mencionado sobre el análisis de precio unitario, señalándose en su parte final que la falta de presentación de cualquiera de los antecedentes allí mencionados, lo excluirá de la licitación.

Seguidamente, expone que el artículo 16 letra b), Doc. 4, de las Bases Administrativas Especiales, establece que se deberá incluir en el sobre caratulado como "Propuesta Económica", el análisis de precio unitario de todos los ítemes del presupuesto oficial, agregándose que el no cumplimiento tanto de la presentación de los documentos como de las exigencias solicitadas en éstos, imposibilitará al oferente de ser adjudicataria de la presente propuesta.

AL SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE
T A L C A

Concluye el citado informe que como las bases administrativas especiales tienen el propósito de complementar las bases generales, prevaleciendo las primeras en caso de existir discrepancia entre ambos instrumentos, debe entenderse que el análisis de precios unitarios debía venir tanto en el sobre de la propuesta técnica como en el sobre de la propuesta económica, exigencia a la que no dio cumplimiento ningún oferente.

Sobre el particular, cabe señalar que del análisis de los antecedentes que se han tenido a la vista se ha podido verificar que el punto 7.1 letra g), de las Bases Administrativas Generales de la licitación expresa que en el sobre "Propuesta Técnica", se deben incluir los antecedentes que allí se enumeran más los que se soliciten específicamente en las Bases Administrativas Especiales, situación que se reitera en la parte final de dicho artículo, donde además se precisa que: "La falta de presentación de cualquiera de los antecedentes antes mencionados, lo excluirá de la licitación", expresión que por cierto, alude a los antecedentes que ambos instrumentos consideren que deben formar parte del sobre denominado "Propuesta Técnica".

Por su parte, las bases administrativas especiales de la licitación establecen que ellas tienen por propósito complementar las bases administrativas generales (B.A.G.) formando, ambas, parte de los documentos que regirán el contrato, agregando que en caso de discrepancia entre las bases, prevalece lo establecido en las presentes bases administrativas especiales.

Pues bien, no obstante que las bases generales establecen que el análisis de precios unitarios debe ser incluido en el sobre denominado "Propuesta Económica", respecto de tal antecedente las bases administrativas especiales, modificaron tal exigencia, consignando en su artículo 16 letra b, doc.4, que debe ser incluido en el sobre caratulado como "Propuesta Económica".

En relación con lo anterior, el informe de adjudicación elaborado para efectos de la licitación en análisis, expresa en cuanto a los oferentes que participaron en el proceso de licitación y no quedaron fuera de bases en el acto de apertura que: "las ofertas presentadas por Constructora Defluv Ltda., Lambda Construcciones Cía. Ltda., Demotrón S.A., y Constructora Cónsul S.A, han sido rechazadas técnicamente por no incluir en su oferta técnica el Doc. análisis de precios como se indica en el artículo 7.1, sobre Propuesta Técnica de las bases administrativas generales, letra G".

En el mismo antecedente consta que tratándose de la propuesta económica se declara fuera de bases a la Empresa Barros y Bruzzone, toda vez que, no obstante haber presentado el documento de análisis de precios unitarios en el sobre "propuesta Técnica", no adjuntó el mismo documento en el sobre de propuesta económica, de acuerdo a lo consignado en el artículo 16 letra B, de las bases especiales," no dándose lectura a su oferta".

Al respecto y en primer término, cabe señalar que en un concurso público el objeto esencial de las formalidades que lo rodean persigue, por una parte, garantizar los derechos del Estado y, por la otra, otorgar por la vía de la transparencia del proceso y de la igualdad de los licitantes, seguridad jurídica a quienes postulan en una licitación llamada por la Administración. Siendo ello así, es preciso consignar que dichos principios son los valores protegidos por el ordenamiento jurídico que regula las solemnidades de la licitación, de manera tal que la inobservancia de las formalidades producirá la ineficacia de la propuesta de un oferente, sólo en la medida que se constate que realmente la omisión tipificada causa desmedro a los derechos del Estado, resta transparencia al proceso o rompe el principio de igualdad de los licitantes en forma tal que la conducta infractora privilegia a uno de ellos en perjuicio de los demás (Aplica criterio contenido en el dictamen Nº 62.483, de 2004).

A mayor abundamiento y aun cuando uno de los principios del sistema de propuesta pública es el de estricta observancia a las bases que lo regulan, fuente principal de los derechos y obligaciones tanto de la Administración como de los oferentes, ello no obsta a que el evaluador deba considerar el interés público que ese principio persigue, por lo que ha de evitar el análisis puramente formalista de las propuestas y obviar las omisiones de detalles carentes de toda relevancia, que no inciden en los aspectos de fondo de cada oferta.

Por su parte, dicho evaluador también ha de tener en consideración el principio de no formalización contemplado en el artículo 13, inciso segundo, de la ley N° 19.880, que señala que el vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado; de este modo, entonces, y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 15.601, de 2009, los errores intrascendentes o no esenciales no constituyen causal suficiente para rechazar postulaciones en procesos concursales. (Aplica criterio dictamen N° 45.757, de 2009)

Ahora bien, en la situación de la especie, la circunstancia que el oferente Barros y Bruzzone Ltda., hubiera acompañado el análisis de precios unitarios en el sobre de propuesta técnica y no adjuntara el mismo documento en el sobre de propuesta económica y, que por su parte, el resto de los oferentes proporcionaran dicho antecedente en este último sobre y no en el primero, no deteriora los intereses del Estado ni tampoco afecta la seguridad jurídica de los oferentes, puesto que lo que naturalmente la Administración debía entender frente a esta situación era que la ausencia de tal antecedente en alguno de los mencionados sobres, se suplía con haberlo incorporado en otro de ellos, ya sea en conformidad a lo establecido en el punto 7.1 de las bases generales o a lo consignado en el artículo 16 de las bases administrativas especiales. Ello, toda vez que se trata de un mismo antecedente que por error de la administración fue solicitado dos veces, no constituyendo aporte alguno a la licitación el acompañarlo en forma duplicada.

Por tal motivo, la circunstancia que los oferentes no acompañaran el análisis de precios unitarios tanto en el sobre de Propuesta Técnica como en el sobre de Propuesta Económica, es un antecedente que debió ser analizado y ponderado en la evaluación técnica y financiera de la oferta, en el ítem "Cumplimiento de las Bases Administrativas Generales y Especiales" a que se refiere el artículo 15 de las bases administrativas especiales, pudiendo influir, asimismo, en su priorización y selección, pero en ningún caso llegar a constituir un motivo de rechazo de las ofertas, como ocurrió en la especie. (Aplica criterio dictamen N° 14.140, de 2009)

Al respecto, se debe tener presente que el principio de razonabilidad obliga a que los órganos del Estado en sus procedimientos de contratación, entreguen a los interesados información coherente y no inductiva a error, como exigencia mínima de seriedad de esos procesos, por lo que siendo obligación de la Administración llevar a cabo procedimientos de licitación públicos, transparentes e imparciales, que permitan a todos los interesados conocer con exactitud el objeto de la convocatoria, a los efectos de que éstos formulen sus ofertas en igualdad de condiciones, es dable sostener que las eventuales diferencias o contradicciones entre los antecedentes que rigen una licitación -y que no hayan sido salvadas con las correspondientes aclaraciones- son, en principio, de responsabilidad de la propia Administración, y, por tanto, ella debe hacerse cargo de las consecuencias de esos errores. (Aplica dictamen N° 44.066, de 2009)

De esta manera, con el mérito de lo expuesto, cabe concluir que la sugerencia formulada por la Comisión de Evaluación en orden a declarar fuera de bases a todas las empresas oferentes, no se ajusta a derecho, debiendo la Dirección de Vialidad adoptar las medidas que en derecho correspondan, destinadas a corregir dicha irregularidad, retrotrayendo el proceso de licitación a la etapa de apertura de las correspondientes ofertas. Ello en el entendido que tal como se consigna en al acta de evaluación de la oferta económica, no se haya dado lectura a la oferta económica de la Empresa Barros y Bruzzone Ltda, de manera de garantizar que los montos allí consignados no hayan sido divulgados ni conocidos por el resto de las empresas oferentes que también fueron declaradas fuera de bases y a quienes en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de las bases administrativas generales tuvo que serles devuelta su propuesta económica.

Lo anterior, por cuanto en aplicación de la doctrina de los actos separables, el procedimiento de licitación está constituido por un conjunto de actos que están interligados, conexos y destinados a producir un determinado resultado que es la elección de quien contratará con la Administración, pero sus sucesivas fases son autónomas y separables entre sí, lo que trae como consecuencia que cada una de ellas puede ser impugnada separadamente por los vicios que específicamente le afecten, de manera que las actuaciones viciadas y, por consiguiente, susceptibles de ser invalidadas, no extienden necesariamente la ilicitud de que adolecen a las demás del procedimiento que sé encuentran ajustadas a derecho. (Aplica dictamen N° 19.014, de 2007)

Finalmente, se debe observar que es improcedente en una propuesta pública o privada que las bases administrativas especiales desconozcan las condiciones o requisitos para participar contemplados en las bases generales, porque aquellas deben aclarar y ser complementarias de éstas, de modo que los oferentes tomen conocimiento en forma precisa y objetiva de las exigencias que deben cumplir para participar en la licitación. Asimismo, las bases especiales sólo pueden entrar a modificar las generales en la medida que estas ultimas lo permitan expresamente lo que no ocurre en la propuesta en análisis, donde por error de la administración las bases especiales modificaron las generales en cuanto al sobre en que debía incluirse el documento "Análisis de Precios Unitarios", toda vez que dicha situación dista de ser complementaria. (Aplica dictamen N° 28073, de 1994)

Saluda atentamente a Ud.,

JOAQUIN CORDOVA MALDONADO
ABOGADO
Contralor Regional
Contraloría General de la Republica
REGION DEL MAULE